

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8327/2544

บริษัทเบลล์โทรโฟน มานูแฟคเจอร์ริง
จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 70 ทวิ, มาตรา 71 (1)

สัญญาซื้อขายที่โจทก์ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย คู่สัญญามีเจตนาแยกเป็นสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์และสัญญาจ้างทำของ ในส่วนสัญญาซื้อขายถือว่าได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยผ่านสถานประกอบการถาวรของโจทก์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่มีสถานประกอบการถาวรตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้จากค่าวัสดุอุปกรณ์โจทก์จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียมเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฯ โจทก์จึงไม่ต้องนำรายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์ในปี 2532 และปี 2533 มาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 และปี 2533 ตามลำดับ

รายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์โจทก์ได้รับยกเว้นภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียมเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และจำเลยไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินกำไรส่วนอื่นออกไปจาก

ประเทศไทย การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจาก
ประเทศไทยตามมาตรา 70 ทวิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว จึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องที่เจ้าพนักงานประเมินประเมินว่าโจทก์มีเงินได้ในปี
2532 ถึง 2534 จำนวน 118,267,462.13 บาท (ที่ถูก 118,267,462.21 บาท)
80,467,420.06 บาท (ที่ถูก 80,467,420.60 บาท) และ 16,267,811.20 บาท (ที่ถูก
16,267,811.76 บาท) นั้นไม่ถูกต้องโจทก์มีหน้าที่เสียภาษีเฉพาะเงินได้อันเกิดจาก
การดำเนินการผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยคือ เงินได้ในส่วนของการ
ให้บริการและดอกเบี้ยสำหรับปี 2532 จำนวน 8,488,600.60 บาท และ 125,435
บาทปี 2533 จำนวน 8,146,568.64 บาท และ 307,767 บาท และปี 2534 จำนวน
10,819,576.56 บาท และ 485,628 บาท เท่านั้น และเงินได้ทั้งหมดของโจทก์ถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โจทก์ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน
ประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยดี หากศาลเห็นว่าโจทก์ควรจะต้อง
เสียภาษี ขอให้มีการสั่งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งหมดจำนวนเงินภาษี เบี้ยปรับ และ
เงินเพิ่ม ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งหกฉบับกับเงินเพิ่ม คำนวณถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 25,537,146.87 บาท ขอให้เพิกถอนแบบแจ้งการประเมินเลขที่
1016/2/100894, 1016/2/100736, 1016/2/100893, 1016/2/100892,
1016/2/100737, 1016/2/100891 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เลขที่ สภ.2/1016/ฝ.2/12/42/228, สภ.2/1016/ฝ.2/16/42/336
ก, สภ.2/1016/ฝ.2/12/42/229, สภ.2/1016/ฝ.2/12/42/230, สภ.2/1016/
ฝ.2/16/42/336 ข, สภ.2/1016/ฝ.2/12/42/231 กับขอให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ทั้งหมดแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1016/2/100894 ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 และเลขที่ 1016/2/100736 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2538 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/228 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2542 และเลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/16/42/336 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 โดยมีให้นำรายรับจากสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 จำนวน 109,653,426.61 บาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 จำนวน 52,302,007.84 บาท มารวมคำนวณเป็นยอดรายรับในการประเมินภาษี และให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายเงินกำไรที่ 1016/2/100892 ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 ที่ 1016/2/100737 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2538 และที่ 1016/2/100891 ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/230 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2542 เลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/16/42/336 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 และเลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/231 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2542 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า เจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) และมาตรา 70 ทวิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 ถึง 2534 ปรากฏตามหนังสือที่ 1016/2/100894 และที่ 1016/2/100892 ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 ที่ 1016/2/100736 และที่ 1016/2/100737 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2538 ที่ 1016/2/100893 และที่

1016/2/100891 ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 เอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 1 ถึง 6 โจทก์ไม่พอใจจึงได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538 และวันที่ 11 มิถุนายน 2539 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 7 ถึง 35 ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยเลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/228, และเลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/230 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2542 เลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/16/42/336 ก และเลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/16/42/336 ข ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 เลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/229 และเลขที่ สภ.2/1016/ผ.2/12/42/231 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2542 ตามเอกสารหมาย จ.2 แผ่นที่ 36 ถึง 41 โดยวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โจทก์สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) และวินิจฉัยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินแต่ให้ลดเบี้ยปรับลงคงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 ทวิ ส่วนเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสองมาตราดังกล่าวตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่อาจงดหรือลดได้ตามกฎหมาย เงินได้ของโจทก์เกิดจากสัญญาที่โจทก์น ประเทศเบลเยียมทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งโจทก์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายรับจากการขายวัสดุอุปกรณ์ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียมเพื่อการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และคดียุติตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งที่ 1016/2/100893 ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตราและรอบระยะเวลาบัญชีปีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า รายได้จากค่าวัสดุอุปกรณ์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 และปี 2533 โจทก์จะต้องนำมาเป็นฐาน

ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 โจทก์มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 118,267,462.21 บาท แยกออกเป็นรายได้จากค่าสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ 109,653,426.61 บาท ค่าก่อสร้างและค่าบริการ 8,488,600.60 บาท ดอกเบี้ยรับ 125,435 บาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2533 โจทก์มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 80,467,420.60 บาท แยกออกเป็นรายได้จากค่าสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ 52,302,007.84 บาท ค่าก่อสร้างและค่าบริการ 8,146,568.64 บาท ดอกเบี้ยรับ 307,676 บาท และเงินได้อื่น ๆ 19,711,168.12 บาท เห็นว่า ตามสัญญาซื้อขายที่โจทก์ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4 โจทก์และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมีเจตนาแยกเป็นสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์และสัญญาจ้างทำของในวันซึ่งสองสถานจำเลยก็ยอมรับว่าโจทก์ได้ทำสัญญาขายวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งชุมสายโทรศัพท์กับวางสายสัญญาณเตือนภัยกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการแยกส่วนของสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างก่อสร้างกับติดตั้งออกจากกัน ในส่วนสัญญาซื้อขายถือไม่ได้ว่าเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยผ่านสถานประกอบการถาวรของโจทก์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่มีสถานประกอบการถาวรตั้งอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้จากค่าวัสดุอุปกรณ์โจทก์จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทย ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 โจทก์จึงไม่ต้องนำรายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์ในปี 2532 จำนวน 109,653,426.61 บาท และในปี 2533 จำนวน 52,302,007.84 บาท มาเป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 และปี 2533 ตามลำดับ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์จากประเทศเบลเยียม แต่โจทก์นำค่าใช้จ่ายในการออกของและค่าภาษีศุลกากรมาเป็นค่าใช้จ่ายและองค์การ

โทรศัพท์แห่งประเทศไทยชำระค่าวัสดุอุปกรณ์ให้แก่บริษัทเบลล์ ประเทศเบลเยียม โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายและภาษีการค้าหัก ณ ที่จ่ายในนามของโจทก์จึงเห็นได้ว่า โจทก์ยอมรับว่าโจทก์มีรายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์และค่าบริการติดตั้ง โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินนั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่ารายได้จากค่าวัสดุอุปกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ อุทธรณ์ของ จำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปมีว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ทวิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532ปี 2533 และปี 2534 ชอบหรือไม่ ในปัญหานี้เห็นควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าโจทก์จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์มิได้จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ส่วนจำเลยนำสืบว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีโจทก์จากการจำหน่ายเงินกำไร เนื่องจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชำระค่าอุปกรณ์โดยส่งเงินไปให้บริษัทโจทก์ในต่างประเทศโดยตรงแต่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จึงถือว่าเป็นการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย การประเมินภาษีใช้วิธีคำนวณย้อนกลับหายอดกำไรที่ส่งออก จำเลยไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินกำไรดังกล่าวเห็นว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่ารายได้ค่าวัสดุอุปกรณ์โจทก์ได้รับยกเว้นภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียม เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และจำเลยไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินกำไรส่วนอื่นออกไปจากประเทศไทย การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจำหน่ายเงินกำไรออกไป

จากประเทศไทยตามมาตรา 70 ทวิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจึงไม่ชอบ
อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สมศักดิ์ วงศ์เย็น-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

งานตามสัญญาระหว่างโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยคดีนี้เป็นงาน
ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องอุปกรณ์เครือข่ายชุมสายโทรศัพท์หากทำเป็นสัญญาจ้างทำ
ของเพียงสัญญาเดียวเหมาทั้งค่าแรงและค่าของโจทก์จะต้องเสียภาษีเงินได้จาก
ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ (ค่าของ)ที่ได้รับจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เพราะแม้ประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศถิ่นที่อยู่ของโจทก์จะมีอนุสัญญาภาษีซ้อน
กับประเทศไทยแต่เมื่องานก่อสร้างและติดตั้งดังกล่าวต้องใช้เวลาเกินกว่า 6 เดือน
กรณีก็ถือว่าโจทก์มีสถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเบลเยียม
ข้อ 5.2(ข) โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 7 ของอนุสัญญาดังกล่าว โจทก์
ต้องเสียภาษีเงินได้จากค่าแรงและค่าของที่ได้รับจากองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย และเมื่อมีการจำหน่ายเงินกำไรจากงานดังกล่าวออกไปจากประเทศไทย

โจทก์ก็ต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่างหากด้วย แต่คดีนี้โจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมิได้ทำเป็นสัญญาจ้างทำของเพียงสัญญาเดียว แต่แยกทำเป็นสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์สัญญาหนึ่งและสัญญาก่อสร้างและติดตั้งอันเป็นสัญญาจ้างทำของอีกสัญญาหนึ่งเพื่อให้โจทก์เสียภาษีเฉพาะจากค่าแรงเท่านั้น ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าของนั้นไม่ต้องเสียภาษี เพราะได้รับยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาดังกล่าวเนื่องจากในส่วนของสัญญาซื้อขายไม่ถือว่าโจทก์มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ทำให้โจทก์ประหยัดภาษีได้มาก การวางแผนภาษีโดยการแยกสัญญาดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร แต่เป็นที่ยอมรับของศาลฎีกา ก่อนคดีนี้ศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยยอมรับการวางแผนภาษีดังกล่าวไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2540 ระหว่างบริษัทเบลล์เทเลโฟนมานูแฟคเจอร์ จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ว่า "นิติกรรมสองฝ่ายหรือสัญญานั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาด้วยคำเสนออีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาด้วยคำสนองรับที่ถูกต้องตรงกัน ดังนั้นหากคู่สัญญาแสดงเจตนาทำเอกเทศสัญญาสองลักษณะต่างกัน แม้จะทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในสัญญาฉบับเดียวกันก็ย่อมกระทำได้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่อย่างใด เมื่อสัญญาซื้อขาย ติดตั้ง และก่อสร้างที่โจทก์ทำไว้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยระบุว่า การจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และการบริการก่อสร้างและติดตั้งเป็นสัญญาที่แยกต่างหากจากกัน และยังได้แบ่งมูลค่าของแต่ละสัญญาออกจากกันจึงต้องตีความเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาว่าโจทก์และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเจตนาทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์กับสัญญาจ้างทำของ (ก่อสร้าง ติดตั้งเครือข่ายและชุมสายโทรศัพท์) แยกต่างหากจากกันเป็นสองลักษณะเอกเทศสัญญาและแยกราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายออกต่างหากจากสินจ้าง หาใช่คู่สัญญาเจตนาทำสัญญาจ้างทำของโดยตกลงให้โจทก์เป็นผู้จัดหาสัมภาระไม่ ขณะที่โจทก์ทำสัญญากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โจทก์ยังไม่มีสถานธุรกิจประจำซึ่งโจทก์

ใช้ประกอบธุรกิจการขายตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยในขณะที่ทำสัญญาขายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แม้การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ขุมสายโทรศัพท์จะเป็นโครงการที่โจทก์ต้องเข้ามาดำเนินการมีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน อันถือได้ว่าโจทก์มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตามข้อ 5.2(ซ)แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียมเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ก็เป็นกรณีที่โจทก์มีสถานประกอบการถาวรสำหรับธุรกิจตามสัญญาจ้างทำของเท่านั้น หาได้มีความหมายว่าสถานประกอบการถาวรดังกล่าวเป็นสถานประกอบการถาวร สำหรับธุรกิจตามสัญญาซื้อขาย (เครื่องมือและอุปกรณ์) ไปด้วยไม่ ฉะนั้น ก่าไรจากธุรกิจขายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ตามสัญญาซื้อขายโจทก์ทำไว้กับ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอันเป็นสัญญาที่แตกต่างหากจากสัญญาจ้างทำของ จึงถือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจโดยผ่านสถานประกอบการถาวรของ โจทก์ในประเทศไทย ดังนั้น โจทก์จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับก่าไรจากธุรกิจ การขายเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวตามข้อ 7.1 แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียมเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และพระราชกฤษฎีกาออก ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18)พ.ศ. 2505 มาตรา 3 ส่วนก่าไรจากธุรกิจการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทำของนั้นไม่ได้รับการ ยกเว้นภาษีเงินได้แต่อย่างใด เมื่อเงินได้ตามสัญญาซื้อขายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เงินได้ดังกล่าวที่มีการจำหน่ายออกไปจากประเทศไทยจึงไม่ต้องเสียภาษีจากการ จำหน่ายเงินก่าไรตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2540 ดังกล่าวกับคดีนี้ ศาลฎีกานำหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาซึ่งเป็น หลักกฎหมายเอกชนมาใช้ ผู้เขียนเห็นว่าการนำหลักกฎหมายเอกชนมาใช้ในการ วินิจฉัยคดีภาษีอากรซึ่งเป็นคดีตามกฎหมายมหาชนนั้นจะต้องกระทำด้วยความ ระมัดระวัง พินิจพิเคราะห์อย่างรอบคอบ มิฉะนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ทำสัญญากันอย่างไรก็ได้เพื่อไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าที่จะต้องเสียตาม
ปกติ ผลก็คือจะต้องเสียภาษีหรือไม่หรือเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ประชาชน มิได้ขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2540 กับ
คดีนี้ เจตนาที่แท้จริงของกลุ่มสัญญาคือการเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ จึงน่าจะถือตาม
เจตนาที่แท้จริงยิ่งกว่าถือเจตนาตามสัญญาแต่ละประเภทคือสัญญาซื้อขายสัญญา
หนึ่ง และสัญญาจ้างทำของอีกสัญญาหนึ่งซึ่งไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงดังนั้น โจทก์จึงน่าจะ
จะต้องเสียภาษีทั้งจากค่าแรงและค่าของมิใช่ค่าแรงอย่างเดียวเท่านั้นและเมื่อมีการ
จำหน่ายเงินกำไรในส่วน of ค่าของออกไปจากประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีตาม
มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรอีกต่างหากด้วย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม